

0000186-62.2020.8.26.0312

Classe: Procedimento Investigatório Criminal (PIC-MP)

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: CARLOS GUILHERME ROMA FELICIANO

Comarca: Juquiá

Foro: Foro de Juquiá

Vara: Vara Única

Data de Disponibilização: 14/12/2022

... Investigatório Criminal (PIC-MP) - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

MULLER APARECIDO DA SILVA AGUIAR

Juiz(a) de Direito: Dr(a). CARLOS GUILHERME ROMA FELICIANO

Vistos.

MULLER APARECIDO DA SILVA AGUIAR, qualificado nos autos, foi denunciado e processado como incurso nas penas do artigo 28 da Lei nº 11.343/06, porque, em tese, no dia 28 ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Juquiá

Foro de Juquiá

Vara Única

Rua Martins Coelho, 439, Juquiá - SP - cep 11800-000

0000186-62.2020.8.26.0312 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

0000186-62.2020.8.26.0312

Classe - Assunto

Procedimento Investigatório Criminal (PIC-MP) - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

MULLER APARECIDO DA SILVA AGUIAR

Juiz(a) de Direito: Dr(a). CARLOS GUILHERME ROMA FELICIANO

Vistos.

MULLER APARECIDO DA SILVA AGUIAR, qualificado nos autos, foi denunciado e processado como incurso nas penas do artigo 28 da Lei nº 11.343/06, porque, em tese, no dia 28 de dezembro de 2019, por volta das 20h28min, na Rua Amazonas, 258, bairro Parque Nacional, nesta cidade e comarca de Juquiá, mantinha consigo, para consumo pessoal, 07 capsulas plásticas contendo cocaína, com peso aproximado de 4.95g, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, conforme auto de exibição e apreensão de fls. 14/15 e exame químico toxicológico definitivo de fls. 44/46.

É o relatório. Passo a fundamentar e decidir.

A conduta ora analisada não merece repressão estatal pela via do Direito Penal. É

princípio jurídico-penal basilar aquele segundo o qual a tutela repressiva do Estado, no âmbito criminal, deve se ater à proteção de bens jurídicos relevantes, reprimindo apenas condutas que tenham aptidão para causar-lhes lesão. Trata-se do princípio da lesividade.

Não se vislumbra, no caso dos autos, qualquer lesão jurídica relevante a qualquer bem jurídico, nem mesmo à saúde pública, dada a inexpressividade da conduta. O réu tinha consigo apenas um pequeno cigarro de maconha, que a testemunha Adriana, em audiência, fez menção de ter algo em torno de cinco centímetros de comprimento, e que era destinado ao consumo próprio e exclusivo do acusado.

É sabido que o Direito Penal não pune a autolesão ou o risco de autolesão, de modo que os eventuais males que o consumo da droga possa fazer ao acusado não autorizam a aplicação da lei penal.

Em sentença proferida em caso análogo, a eminente magistrada deste Eg. TJSP, Ana Rita de Figueiredo Nery, pontuou:

"Em uma sociedade plural, como preconizado no Preâmbulo da Constituição Federal, pessoas têm convicções diferentes, encontrando bem-estar de maneiras distintas e arcando com as consequências pessoais de tal ou qual decisão. Nesta sociedade, o Estado só age para evitar que a conduta de uma pessoa interfira na vida de outra, garantindo o exercício harmônico das liberdades humanas. Adotada esta premissa, a proibição do uso de drogas é inconstitucional. O porte de drogas para uso próprio diz respeito apenas ao usuário. Não é possível dizer a priori que este, ao consumir drogas, vai cometer qualquer crime. De todo modo, se isso ocorrer, haverá a punição pelo crime cometido. Tampouco é válida a afirmação de que existirá punição pelo crime cometido com vistas à drogadição. Tomado em si mesmo, o uso de drogas nada gera além da alteração de consciência, obtida também por meio de substâncias lícitas, como o álcool e o tabaco. Não há coerência na permissão de umas e proibição de outras. Tem-se, daí, a intenção estatal de impor um padrão de conduta, decorrente de uma suposta maioria, tratando como crime (com todas as consequências seríssimas decorrentes, incluindo a inclusão de maus antecedentes) aquilo que, de há muito se diz, deveria ser tratado como questão de saúde pública. Inválido, juridicamente, o argumento corrente de que a criminalização se justificaria no combate ao tráfico. Embora com alguma lógica cartesiana, a afirmação esbarra no princípio de que, em direito penal, as condutas devem ser individualizadas, não se punindo aquele que não causou, direta ou indiretamente, o perigo ou o dano. Por tal razão, apenas o traficante deve ser punido pelo mal que gera: a distribuição das drogas sem nenhuma preocupação com as consequências que sua disseminação causará. Por tudo isso, entende-se que a criminalização do uso de drogas, ou do porte para o uso delas, configura restrição indevida da liberdade, com violação ao que dispõe o artigo 3º, IV, da Constituição Federal, dispositivo que veda todas as formas de discriminação" (autos nº 0003291-24.2016.8.26.0268).

Em outras palavras, o artigo 28 da Lei nº 11.343/2006 não se harmoniza com o direito fundamental à intimidade e à vida privada, previsto no artigo 5º, inciso X, da Constituição Federal, porque visa à punição de uma conduta cuja repercussão se restringe ao âmbito interno do indivíduo.

Também não há compatibilidade entre a criminalização da posse de drogas para uso pessoal e alguns dos princípios fundamentais do Direito Penal, a saber, os da lesividade, da fragmentariedade, da alteridade, da exclusiva proteção a bem jurídicos e da intervenção mínima.

A esse respeito, o precedente deste Eg. TJSP: "(...) 2 - O artigo 28 da Lei n. 11.343/2006 é inconstitucional. A criminalização primária do porte de entorpecentes para uso próprio é de indisfarçável insustentabilidade jurídico-penal, porque não há tipificação de conduta hábil a produzir lesão que invada os limites da alteridade, afronta os princípios da igualdade, da inviolabilidade, da intimidade e da vida privada e do respeito à diferença, corolário do princípio da dignidade, albergados pela Constituição Federal e por tratados internacionais de Direitos Humanos ratificados pelo Brasil. (...)" (Ap. Criminal 0023470-50.2006.8.26.0196, Rel. José Henrique Rodrigues Torres, 6ª Câ. de Direito Criminal, j. em 15-6-2009, DJe 18-8-2009).

Quanto ao princípio da alteridade, segundo o qual não pode o direito penal sancionar a lesão que não transcenda o âmbito interno do próprio agente, convém transcrever a importante lição doutrinária de Paulo Queiroz:

"Somente podem ser erigidos à categoria de criminosos fatos lesivos de bem jurídico alheio, e não atos que representem uma "má disposição" de direito próprio. Nesse sentido, aliás, é o "núcleo" do Direito Penal brasileiro, visto que não se pune o suicídio tentado, a automutilação, o dano à coisa própria etc., mesmo porque semelhante intervenção seria de todo inútil, isto é, desprovida de capacidade motivadora. E é também por isso que soam claramente inconstitucionais disposições como a do art. 16 da Lei n. 6.368/76 (porte ilegal de entorpecentes) [atualmente previsto no art. 28 da Lei n. 11.343/2006] ou a contravenção de mendicância (LCP, art. 60)" (Direito penal e liberdade, Boletim IBCrim, p. 5).

Já Gustavo Junqueira e Patrícia Vanzolini explicam que "embora o princípio da alteridade não seja nominalmente citado no texto constitucional, assim como o da exclusiva proteção a bens jurídicos, ele deflui diretamente dos valores agasalhados pela Constituição e pelo Estado Democrático de Direito. O art. 5º, X da Carta Magna considera invioláveis a intimidade e a vida privada. Tal dispositivo protege as escolhas dos indivíduos no âmbito privado, desde que não ofensivas a terceiros. Decorre dessa proteção, portanto, que determinado fato, para que possa ser definido como crime, há de lesionar bens jurídicos alheios, de modo que condutas, por lesivas que sejam, mas que se restrinjam ao âmbito privado agente, não podem ser objeto da tutela penal" (Junqueira, Gustavo Octaviano, D. e Maria Patricia Vanzolini Figueiredo. Manual de Direito Penal. Disponível em: Minha Biblioteca, (7th edição). Editora Saraiva, 2021).

Vale mencionar, ainda, que pende de julgamento pelo Supremo Tribunal Federal o Recurso Extraordinário 635.659, versando sobre caso que envolvia a condenação do recorrente pelo consumo de 3 gramas de maconha, em que se discute a (in)constitucionalidade do artigo 28 da Lei de Drogas.

Já votaram, no referido Recurso Extraordinário, três Ministros da Corte, todos eles em favor da declaração de inconstitucionalidade do dispositivo.

É digno de reprodução o importante trecho do voto proferido pelo Eminente Ministro Luis Roberto Barroso, transcrito por Junqueira e Vanzolini na obra acima referenciada: "O denominado princípio da lesividade exige que a conduta tipificada como crime constitua ofensa a bem jurídico alheio. De modo que se a conduta em questão não extrapola o âmbito individual, o Estado não pode atuar pela criminalização. O principal bem jurídico lesado pelo consumo de maconha é a própria saúde individual do usuário, e não um bem jurídico alheio. Aplicando a mesma lógica, o Estado não pune a tentativa de suicídio ou a autolesão. Há quem invoque a saúde pública como bem jurídico violado. Em primeiro lugar, tratar-se-ia de uma lesão vaga, remota, provavelmente em menor escala do que, por exemplo, o álcool ou o tabaco. Em segundo lugar porque, como se procurou demonstrar, a criminalização termina por afastar o usuário do sistema de saúde, pelo risco e pelo estigma. De modo que pessoas que poderiam obter tratamento e se curar, acabam não tendo acesso a ele. (...) A criminalização de condutas relacionadas ao consumo promove a exclusão e a marginalização dos usuários, dificultando o acesso a tratamentos. Como assinalou o antropólogo Rubem César Fernandes, diretor do Viva Rio: 'O fato de o consumo de drogas ser criminalizado aproxima a população jovem do mundo do crime'. Portanto, ao contrário do que muitos creem, a criminalização não protege, mas antes compromete a saúde pública".

Seja como for, ainda que não se considerasse inconstitucional o dispositivo incriminador, o fato ora apurado, pela ínfima quantidade de droga apreendida (1,80g – massa líquida – fls. 45), não se amolda materialmente à figura típica, por força do princípio da insignificância.

Em outras palavras, dada a minúscula quantidade de droga apreendida, o fato é materialmente atípico, porque a lesão jurídica, se existente, é inexpressiva.

A propósito, o recente precedente do STF: "Penal e processual penal. Habeas corpus. Possibilidade de aplicação do princípio da insignificância em porte de entorpecentes para consumo pessoal. 1. A aplicação do princípio da insignificância, de modo a tornar a conduta atípica, exige sejam preenchidos, de forma concomitante,

os seguintes requisitos: (i) mínima ofensividade da conduta do agente; (ii) nenhuma periculosidade social da ação; (iii) reduzido grau de reprovabilidade do comportamento; e (iv) relativa inexpressividade da lesão jurídica. 2. Paciente que portava 1,8g de maconha. Violação aos princípios da ofensividade, proporcionalidade e insignificância. 3. Precedentes: HC 110475, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 15.3.2012; HC 127573, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 25.11.2019. 4. Ordem concedida para trancar o processo penal diante da insignificância da conduta imputada" (HC 202.883/SP, rel. Min. Gilmar Mendes, j. 3 a 14 de setembro de 2021 – sessão virtual).

Neste Eg. Tribunal de Justiça de São Paulo:

"Apelação. Porte de entorpecentes para consumo próprio. Condenação. Recurso exclusivo da defesa. Acusado flagrado em poder de apenas um cigarro de maconha, parcialmente consumido, com peso de dois gramas. Atipicidade material da conduta. Aplicação excepcional do princípio da insignificância no caso concreto. Ausência de qualquer perigo de lesão à saúde pública. Incidência dos princípios da subsidiariedade, da fragmentariedade e da ofensividade, nos moldes do Direito Penal mínimo. Absolvição que se impõe. Reforma da sentença. Recurso provido" (TJSP; Apelação Criminal 0003908-96.2015.8.26.0048; Relator (a): Guilherme de Souza Nucci; Órgão Julgador: 16ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Atibaia - 2ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 10/11/2015; Data de Registro: 04/04/2019).

Ante o exposto, reconheço a atipicidade material da conduta, para, com fundamento no art. 386, III, do Código de Processo Penal, JULGAR IMPROCEDENTE a pretensão punitiva formulada em face de MULLER APARECIDO DA SILVA AGUIAR.

Proceda-se à incineração da droga apreendida.

Feitas as anotações e comunicações necessárias, arquivem-se os autos.

Custas na forma da lei, observada a gratuidade de justiça.

Publicada pela liberação nos autos digitais.

Registro dispensado (NSCGJ, art. 72, § 6º)

Intimem-se. Comunique-se.

Juquiá, 14 de dezembro de 2022.